

比例原则视角下家庭教育指导令的制度完善

李 雪

(海南师范大学 法学院,海南海口 570100)

摘要：《家庭教育促进法》的实施使家庭教育指导令备受关注,在其被广泛适用的同时,也产生了诸多争议。家庭教育指导令的困境主要体现在规则、实践、价值三个维度,比例原则作为平衡利益冲突的有效工具,对解决当前困境具有重要启发。基于比例原则的适当性原则、必要性原则、均衡性原则三个子原则的指导分析,家庭教育指导令在规则制定上应当遵循以教育为主,惩罚为辅;在实践应用中应当明确其辅助性定位;在价值衡量过程中应当以最有利于未成年人为价值判断。依据以上对家庭教育指导令的应然界定,应当从设定“温和”法律责任、构建事前审查体系、提供专门化家庭教育支持三个方面进行制度完善。

关键词：家庭教育指导令;比例原则;国家教育权;最有利于未成年人原则;受教育权

中图分类号：D924.3

文献标志码：A

文章编号：1009-8003(2026)03-0000-11

《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《家庭教育促进法》)在2022年1月1日正式实施,标志着我国家庭教育进入了法治化、规范化发展的新阶段。其中第四十九条关于“家庭教育指导令”的规定备受关注,这是继《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》之后,立法再一次确认了这项强制亲职教育制度。家庭教育指导令是国家介入家庭教育的一种手段,当发现未成年人存在严重不良行为或者实施犯罪行为,未成年人的父母或者其他监护人不正确实施家庭教育侵害未成年人合法权益时,国家可以制发家庭教育指导令。截至2022年5月,北京市全市法院累计发出家庭教育指导令116份^①。2023年,山东省全年共向612名家长制发了家庭教育指导令。^②家庭教育指导令的广泛适用也暴露出了许多问题,由于三部法律对家庭教育指导令只是概括性规定,导致各地在适用家庭教育指导令时做法不一。2023年5月最高人民法院、全国妇联共同印发了《关于开展家庭教育指导工作的意见》(以下简称《指导意见》),回应了家庭教育指导令的适用情形、文书格式以及异议程序的问题,进一步推动了家庭教育指导令的规范发展。但目前看,家庭教育指导令的诸多理论困惑和制度困境仍没有得到妥善解决。

一、家庭教育指导令的三重困境

(一) 规则之困:不接受家庭教育指导令的法律后果缺失

纵观家庭教育指导令的法律规定,在《未成年人保护法》中,“未成年人的父母或者其他监护人不依

收稿日期:2025-12-13

基金项目：本文系国家社科基金一般项目“中国阻断法的立法与应用研究”(21BFX145),中国青少年研究会2025年度研究课题“比例原则视角下青少年家庭教育立法研究”(2025B47)的阶段性成果。

作者简介：李雪(1991-),女,法学博士,海南师范大学法学院讲师,主要研究方向:环境法学、教育法学。

①北京市人民政府:“《家庭教育促进法》实施5个多月,助力家校社会协同育人,法院发出教育责任告知书等116份”,载https://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/sy/jrts/202205/t20220513_2708956.html,2025年10月27日访问。

②山东省高级人民法院:“2023年山东各级法院依法向612名家长发出家庭教育令”,载http://www.sdcourt.gov.cn/nwglpt/_2343835/_2532828/15140226/index.html,2025年10月27日访问。

法履行监护职责或者侵犯未成年人合法权益的”,可以责令其接受家庭教育指导;在《预防未成年人犯罪法》中,“公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中发现实施严重不良行为的未成年人的父母或者其他监护人不依法履行监护职责的”,可以责令其接受家庭教育指导;在最初的《家庭教育法(草案)》当中规定了家长不接受家庭教育指导令的,由公安机关予以警告,责令其改正;拒不改正的,可以根据情节轻重处以 1 千元以下罚款、5 日以下拘留。但最终《家庭教育促进法》删除了不接受家庭教育指导令的法律后果,规定“公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中,发现未成年人存在严重不良行为或者实施犯罪行为,或者未成年人的父母或者其他监护人不正确实施家庭教育侵害未成年人合法权益的”的情形下,可以责令其接受家庭教育指导。由此可见,家庭教育指导令的规定范式都是在满足条件的情形下,可以适用家庭教育指导令。

相关法律对于不接受家庭教育指导令将承担何种法律责任没有做进一步规定,这导致在家庭教育指导令的司法实践中,不同法院制发的家庭教育指导令的法律后果也存在显著差异性:有的家庭教育指导令规定根据情节轻重对当事人进行训诫、罚款、拘留,有的家庭教育指导令将不履行家庭教育指导令视为建议法院撤销当事人监护人资格的参考,还有的家庭教育指导令并没有附加任何法律责任。法律责任的缺失导致家庭教育指导令的司法实践相互冲突,进而影响家庭教育指导令制度的稳定性和有效性。因此,是否应在家庭教育指导令中附加法律责任,以及应附加何种法律责任,已成为家庭教育指导令统一适用的关键问题。

(二) 实践之困:家庭教育指导令的适用范围过大

从《家庭教育促进法》第四十九条中可以看出,制发家庭教育指导令的两种适用情形:一是未成年人存在严重不良行为或者实施犯罪行为;二是监护人不正确实施家庭教育侵害未成年人合法权益。第一种情形中的“严重不良行为”在《预防未成年人犯罪法》的第三十八条中做了详细的列举,“犯罪行为”的界定更无需赘述。然而,第二种情形却在司法实践中呈现出适用范围不断扩大的趋势。

首先,“不正确实施家庭教育”的内涵在司法实践中被过度扩张,部分案件混淆了监护职责与家庭教育之间的界限。以周某等与朱某确认收养关系纠纷案为例^①,周某和赵某在他人介绍下,将他们的次女交由结婚多年却未能生育的朱某夫妇抚养。双方私下签署了一份送养协议,但并未前往民政部门完成正式的收养登记。随后,周某和赵某改变主意,试图要回次女,但未能成功,因此他们向清江浦区法院提起诉讼,请求法院确认他们与朱某夫妇之间的收养(送养)关系不成立。在审理此案的过程中,清江浦区法院依据《家庭教育促进法》发出了家庭教育指导令,旨在督促和引导父母正确履行对未成年子女的监护责任。通常认为,监护职责包括保护被监护人的身体健康、照顾被监护人的生活、管理和保护被监护人的财产、代理被监护人进行民事活动、对被监护人进行管理和教育。显然,家庭教育属于监护职责中对被监护人进行管理和教育的一个面向。这个案例违反的是监护职责中照顾被监护人生活的义务,并不属于家庭教育范畴。法院依据《家庭教育促进法》发出指导令,实际上混淆了家庭教育与监护职责的法律边界,超越了该法规定的适用范围。^②

其次,司法实践中对“不正确实施家庭教育”与“未成年人权益受侵害”之间因果关系的认定存在随意化、模糊化现象。例如,在陈某某猥亵儿童、强奸、强制猥亵案中,陈某某用过威胁、诱骗等手段与多名未成年女性发生性关系。检察机关以多名被害人由于父母疏于管教、关爱,导致沉迷网络并渴望通过异性爱恋弥补感情缺失而被侵害的问题为由,向多名被害人家长发出家庭教育指导令。^③在这一类型的案件当中,未成年人利益受到侵害虽是客观事实,但与监护人是否进行正确家庭教育并无直接的因果关

①参见《江苏省淮安市中级人民法院发布 2021 年度十大典型案例之十:周某等与朱某确认收养关系纠纷案——责令疏于履行教养义务的家长接受家庭教育指导案》(法宝引证码:CLI. C. 410035429),载北大法宝网, <https://www. pkulaw. com/pfnl/95b2ca8d4055fce11d69889455fa4fa48d3564dea0779004bdfb.html>, 2025 年 11 月 03 日访问。

②参见吴进娥:《我国司法强制亲职教育的缘起与规范发展研究》,载《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2023 年第 1 期。

③参见《最高人民法院、中华全国总工会、中华全国妇女联合会联合发布 12 起保障妇女儿童权益典型案例之三:陈某某猥亵儿童、强奸、强制猥亵案》(法宝引证码:CLI. C. 549863188),载北大法宝网, <https://www. pkulaw. com/pfnl/08df102e7c10f206bec818c3fd659c6df9b42f9f083360c7bdfb.html>, 2025 年 10 月 03 日访问。

系。司法实践未能充分论证因果关系,便一概适用家庭教育指导令,进一步扩大了家庭教育指导令的适用边界。

综上所述,当前司法实践对家庭教育指导令的适用存在明显扩张趋势,不仅混淆了监护职责与家庭教育的界限,也未能严格认定家庭教育与未成年人权益受侵害之间的因果关系。这种适用范围的过度扩张,必然削弱家庭教育指导令的针对性与法律威信,应引起司法机关与立法机关的高度重视和谨慎反思。

(三) 价值之困:家庭教育指导令的多元利益衡量不足

家庭是一个相对封闭和私密的空间,是成员间情感交流、价值观传承和生活技能学习的主要场所。在这个环境中,家长与子女之间的关系是基于血缘、婚姻或法律关系的,这种关系的亲密性和排他性决定了家庭教育的高度私密性。但同时,家庭教育的社会性又要求在家庭失灵的情况下国家能介入其中,家庭教育指导令便是国家的介入手段之一。当前的家庭教育中,涉及三方的利益,即国家教育权、家长教育权和未成年人的合法权益。家庭教育指导令旨在纠正家长错误的家庭教育方式,使未成年人得到保护,但过度的介入可能会束缚家长的教育自主性。

《家庭教育促进法》设立专章以明确家长在家庭教育中的责任。这一章节详细阐述了家长应当如何进行家庭教育,包括教育的内容、方式和方法。通过这些规定,法律试图勾勒出一个理想家长的形象,为家长提供一个明确的教育指南。如果家长未能按照这些规定来实施家庭教育,那么他就可能被视为未能正确实施家庭教育。然而,在现实生活中,家长常常会因为各种生活压力,或者价值观念的差异,无法完全按照法律规定来实施家庭教育。有些家长可能因为工作繁忙,无法抽出足够时间来陪伴和教育孩子;有些家长则可能因为个人信仰和价值观的不同,选择了一种与法律要求不同的教育方式。如果将“忙于生计导致对未成年子女关心不足”这种令人无奈的情况都视作适用家庭教育指导令的情形,就会产生国家过度介入家庭教育而侵犯家长教育权的问题。

在未成年人的成长过程中,家庭、学校以及社会都起到了一定的教育作用。未成年人不法行为的发生,可能是因为父母的教育观念和方法不当,如过于溺爱或放任自流,都可能导致孩子形成不良性格和行为习惯;也可能是学校片面追求成绩的提升,忽视德育和法治教育,导致一些学生道德品质和法律意识淡薄;还可能是社会上存在的拜金主义、享乐主义等不良风气,对未成年人产生诱惑。美国有一项关于未成年犯罪的研究表明,虽然导致未成年人犯罪的原因仍没有可靠答案,但可以肯定的是,大部分的致因影响来自于家庭之外^①。未成年人存在严重不良行为或者实施犯罪行为时,家长不正确的家庭教育可能只是一个诱因,但家长却成为了唯一承担法律责任的主体,这显然过度损害了家长的利益。

二、比例原则视角下家庭教育指导令的实然检视

比例原则是许多国家行政法上一项重要的基本原则,包括适当性原则、必要性原则和均衡性原则三个子原则。它要求行政机关在行使职权时,必须全面权衡所追求的公共利益和个体利益,确保行政行为的合理性和有效性。在现代法治社会中,比例原则不仅适用于公法领域,还在一定程度上适用于私法领域。比例原则的核心在于通过目的与手段间的衡量,兼顾国家、社会及公共利益,同时又不妨害第三人的权利,确保基本人权的实现。

家庭教育指导令是公安机关、检察机关、人民法院制发的用以矫正家长的不正确家庭教育的法律文书,其涉及衡量多方利益。家庭教育指导令的制发方和接受方具有不平等的地位,制发方作为公权力机关,在防止家长不正确行使教育权的同时,也可能限制家长正常行使教育权。比例原则恰是防止公权力机关滥用职权,保障公民合法权益的有效工具,能够有效平衡国家、家长和未成年人之间的利益。家庭教育指导令的适用与比例原则具有目的性和工具性的契合,比例原则在匹配手段目的、厘清适用范围、均衡多元利益方面对当前家庭教育指导令的困境具有重要指导意义。

^①Sol Rubin. *Crime and Juvenile Delinquency: A Rational Approach to Penal Problems*, New York, Oceana Publications.39.

(一) 家庭教育指导令的适当性考量不充分

在法教义学中,目的与手段之间存在着相互依存与促进的内在联系,公权力行为的手段必须具有适当性,能够促进所追求目的之实现。^① 国家介入家庭教育最直接的目的就是保护未成年人的合法权益,家庭教育指导令作为手段之一,应当有助于实现未成年人合法权益的保护。依据上文,实践中对于不履行家庭教育指导令的三种法律后果,从训诫、罚款、拘留到建议法院撤销当事人监护人资格,再到没有任何法律责任,惩罚属性逐渐减弱,教育属性逐渐增强,折射出了签发者对家庭教育指导令的工具价值判断。这种多样化的处理方式也反映出在手段与目的之间的匹配性上存在考量不足的问题。因此,确保手段与目的的高度契合,是当前亟需解决的问题。

以拘留作为不履行家庭教育指导令的法律后果为例,这种做法将家庭教育指导令视为一种以惩罚性为主的手段。然而,过度的惩罚性实际上是对家长教育行为的一种极度否定性评价,这种评价可能会引发家长的羞愤心理。这种心理反应不仅可能对孩子在家教育中的成长造成更负面的影响,还可能导致家长在未来遇到需要家庭教育指导时,更少地寻求帮助。此时,家庭教育指导令的惩罚性超越了其原本保护未成年人合法权益的目的,使得二者之间发生了偏离。相反,以不履行家庭教育指导令没有任何法律后果为例,这种做法认为家庭教育指导令仅仅是一种教育手段。当家庭教育指导令作为这种十分温和的手段,面对那些需要家庭教育指导却缺乏自知之明的家长时,即使制发了家庭教育指导令,也很难确保其实施效果。仅仅具有教育性的家庭教育指导令,无法有效地达到保护未成年人合法权益的目的。因此,我们对家庭教育指导令的属性厘定,既要确保其具有一定的约束力,以促使家长认真对待家庭教育指导令,又要确保其具有足够的教育性,以真正达到教育和保护未成年人的目的。只有这样,家庭教育指导令才能在实际操作中发挥其应有的作用,既不会过度惩罚家长,也不会失去应有的教育本质。

(二) 家庭教育指导令的适用范围必要性分析不到位

依照必要性原则,家庭教育指导令的适用应当保障家长教育权的最低损害,它的扩大适用是对家长教育权的过度侵犯,主要原因在于审查方法不规范和审查程序不完善。

首先,审查方法不规范的原因之一是对家庭教育指导令的定位把握不准确。部分司法人员对于家庭教育指导令持有应用尽用的态度,忽视了必要性原则。家庭教育指导令具有强制性,对家长的利益会造成一定损害,所以司法人员应当考虑是否有损害更小的方式能够实现未成年人保护、家庭和谐幸福、社会稳定的目的,而不是一味制发家庭教育指导令。其次,审查方法不规范的另一个原因是审查人员专业性有待提高。在判断家庭教育指导令的适用条件时,审查人员对“不正确家庭教育”,以及“不正确家庭教育”与“侵害未成年人合法权益”的因果关系存在错误判断。并且,审查人员对这个过程缺乏细致的调查和深入的分析。对适用条件的判断应当基于对家庭内外部关系及情况的信息进行全面的收集,并且应当依据每个家庭的特殊性对相关因素进行分析。如果仅凭主案件的案情简单决定是否发出家庭教育指导令,而没有对关键要素进行充分判断,可能会过度损害家长利益。

(三) 家庭教育指导令的多元利益均衡性分配不全面

家庭教育指导令作为国家介入家庭教育的手段,其适用尺度实际上就是国家介入家庭教育的界限。如果国家对家庭教育介入不足,则不能有效保护未成年人利益;而如果国家对家庭教育介入过度,则可能侵害家长利益。

家庭教育指导令是《家庭教育促进法》中的一个重要组成部分,旨在通过法律手段来规范和引导家庭教育,以期达到增进家庭幸福和促进社会稳定的双重目的。然而,在实际操作过程中,家庭幸福和社会稳定这两个目标有时会出现不一致的情况。例如,一些家庭的教育理念深受传统家庭教育的影响,他们认为家长应该树立权威,需要通过严格的管教方式来对未成年子女进行教育,以确保子女的健康成长

^①参见刘权:《目的正当性与比例原则的重构》,载《中国法学》2014 年第 4 期。

和家庭的和谐稳定。然而,《家庭教育促进法》却强调家长与未成年子女之间应当进行平等的交流。^①在这种情况下,如果适用家庭教育指导令,强制改变家长的教育方式,可能会对家庭的幸福感产生负面影响。家长可能会感到困惑和无助,甚至产生抵触情绪,从而导致家庭关系的紧张和矛盾。可见,家长在教育子女时应当有一定的自主权,可以根据自己的实际情况和孩子的具体需求来选择最适合的教育方式,而不是完全受限于法律勾画的完美形象。因此,在实际操作中,应当对家长的实际情况进行综合考量,既要确保家庭教育的质量,又要尊重家长的教育自主权。

三、比例原则下家庭教育指导令的应然界定

当前家庭教育指导令在内涵和性质上仍有许多争议和困惑,运用比例原则分析成因后,应当依循比例原则进一步厘清家庭教育指导令的内在机理,为其制度完善提供理论架构。

(一) 规则制定应当以教育为主,惩罚为辅

学界对于家庭教育指导令的制度属性存在诸多争议:有的学者认为家庭教育指导令是惩戒“失职”监护人^②;有的学者认为家庭教育指导令是支持、协助“失职”监护人^③;还有的学者认为家庭教育指导令兼具惩戒和协助“失职”监护人两个属性^④。对家庭教育指导令的制度属性厘定,应当从何种属性更能能够实现制度目的入手。

1. 家庭教育指导令兼具惩罚性和教育性。《家庭教育促进法》的“法律责任”章节中采用“责令其接受家庭教育指导”的表述。现代社会,法律的惩罚性是针对人的社会性作出的,不能仅认为是一种社会性报复,也更不能简单的认为是一种教育,而是施以隔离措施的行为禁制。^⑤判断“责令其接受家庭教育指导”是否具有惩罚性,应当考察“失职”家长是否有法律义务的增加。家庭教育指导令的惩罚性体现在:第一,“责令其接受家庭教育指导”是国家强制力的要求,失职家长必须接受;第二,失职家长必须改正达到正确效果,体现出对错误行为的纠正;第三,改正行为在一定期限内,并非失职家长可以根据自己意志无限期的行为。以上都体现家庭教育指导令通过加重失职家长法律义务,使其成为更好的家长,最终降低未成年人犯罪率、保护未成年人合法权益的司法意图。

除了家庭教育指导令的惩罚性,还应当关注到它也具有教育属性。家庭教育立法在起草过程中,法律草案(一审稿)名称为《中华人民共和国家庭教育法》,后在公开征集意见后,二审稿法律草案修改为《中华人民共和国家庭教育促进法》。相较于普通法的规范和调整功能,促进法更侧重引导和激励,通过结合硬法的强制约束力和软法的动员、宣传、鼓励作用实现治理目标。“促进”在立法名称中的加入,意味着家庭教育立法以规范家庭教育活动为主改为支持家庭教育为主,明确了国家指导、支持和服务的立法理念。^⑥除此之外,第四章的章名由“家庭教育干预”改为“社会协同”,并删除了一审稿中罚款、拘留等惩罚性较强的措施,只保留了“训诫”“责令”等弱规制措施。这些都表明了国家对家庭教育的“支持”角色定位。^⑦

可见,家庭教育指导令既具有惩罚功能,也具有教育功能,但两个属性在家庭教育指导令中的权重决定了它的实施效果,因此厘清二者定位十分重要。

2. 应当限缩家庭教育指导令的惩罚性。过度强调家庭教育指导令的惩罚性会降低其有效性。有研究显示,惩罚家长并未降低未成年人严重不良行为和犯罪率。美国法官保罗·W·亚历山大研究了他所在法庭 1937 至 1946 年的记录,涉及超千起未成年人不良行为案件,其中四分之三家长被判有罪并受

①《中华人民共和国家庭教育促进法》第十七条规定:未成年人的父母或者其他监护人实施家庭教育,应当关注未成年人的生理、心理、智力发展状况,尊重其参与相关家庭事务和发表意见的权利,合理运用以下方式方法:……;(七)平等交流,予以尊重、理解和鼓励;……。

②参见谭佐财:《“依法带娃”:家庭教育令的法律实现》,载《兰州学刊》2022 年第 10 期。

③参见李泊毅:《家庭教育指导令的规范化》,载《预防青少年犯罪研究》2022 年第 3 期。

④参见李建云:《家庭教育指导令的法律属性、程序法定位及程序规则建构》,载《少年儿童研究》2024 年第 5 期。

⑤参见张康之:《法律惩罚的哲学解读》,载《江南社会学院学报》2004 年第 6 期。

⑥参见叶强:《学术史视野下的家庭教育立法研究(1992-2021)——回顾与展望》,载《教育学术月刊》2023 年第 4 期。

⑦参见李曼:《家庭教育地方立法的实践探索与理性思考》,载《北京社会科学》2021 年第 5 期。

罚,但这对未成年人犯罪率无明显影响。亚历山大认为,惩罚父母对遏制不良行为无效。^①相反,过度强调家庭教育指导令的惩罚性会降低其实效。首先,惩罚性会让接受家庭教育指导令的家长感到挫败和羞耻,在今后不愿寻求国家帮助。其次,未成年人可能利用此威胁家长,导致家庭不和。最重要的是,只惩罚家长的行为破坏了国家与家长间应共同承担责任的合作关系。

过度强调家庭教育指导令的惩罚性违反了责任相称原则。首先,这种过度惩罚性导致家庭教育指导令的责任与家长的失职行为不相适应。未成年人的成长受家庭、学校和社会多方面影响,当未成年人出现严重不良行为或犯罪时,家长不正确的家庭教育可能只是诱因,但家长却成为唯一受惩戒的主体,这显然不合理,因为老师或学校同样负有教育责任。其次,过度惩罚性还与家长的主观过错程度不符。家庭教育指导令通常针对有主观过错的家长,但许多家长失职并非故意,而是受观念、压力或情感困扰,他们更需要帮助而非惩罚。有些家长已全力满足孩子需求,说明这些家长并无主观过错,如果过度强调家庭教育指导令的惩罚性,对他们制发家庭教育指导令,会使其承担过重的法律责任。

3.应当凸显家庭教育指导令的教育性。凸显家庭教育指导令的教育性是国家介入家庭教育的正确路径。家庭教育充满情感,父母对孩子的爱是主观且无法量化的。这种爱既体现在物质援助上,也体现在精神关怀上,随着孩子成长而变化,可能表现为严格教导或温柔呵护。它涉及情感投入、无私奉献和亲情纽带。然而法律难以适应这种复杂的情感表达,无法衡量爱的深度和广度。因此,国家介入保护未成年人时应审慎,避免不准确的适用产生负效应,应当通过教育、支持和服务帮助父母改善行为,家庭教育指导令应以教育性为主。

凸显家庭教育指导令的教育性有利于提升家长教育能力。家庭教育指导令的核心在于保障未成年人权益,引导家长正确履行家庭教育职责,而非惩罚家长。若家庭教育指导令内容偏向惩罚,则可能引发社会对家长教育方式的负面评价。家庭作为教育子女的独立单位,其教育管理具有私密性和伦理性,本身就排斥国家过度干预。国家不当介入可能使家长感到无助或愤怒,进而影响其子女教育态度。相反,若家庭教育指导令被视为家长教育的支持工具,困境中的家长会更愿意主动寻求帮助。家庭教育指导令要求家长细心照料孩子学习、生活,关注其身心健康,旨在教育家长有效实施家庭教育,增进家庭幸福。因此,法院从教育视角出发制发指导令,能激发家长学习提升家庭教育能力的积极性,促进家庭教育健康发展。^②

(二) 司法适用应当明确其辅助性地位

司法实践中家庭教育指导令的扩大适用是因为,司法人员在行使自由裁量权时,对家庭教育指导令在家庭教育当中的地位把握不当,对适用条件缺乏专业判断所致。赋予家庭教育指导令最大的司法力度,并不代表能取得最优的制度效果。^③明确家庭教育指导令的辅助性的定位才能更有效地发挥其效能。

1.国家在家庭教育中应当处于辅助地位。未成年人既是家庭的组成成员,也是国家未来的缔造者,国家以减少犯罪、维护社会安全为缘由,将公权力拓展至家庭私域,这种公权力的渗透可能会带来保护子女、保障社会的正面效应,但若是单纯为通过掌控家庭秩序来实现维护社会秩序的功利目标,会过度干涉家庭自主或将破坏家庭的自然结构,进而威胁未成年人的权益。比如在古代,国家权力强势渗透家庭教育的背景下,孝道成为了古代家庭教育最为关键的一环,主要涵盖三个层面:最低层级为“养”,更进一层为“敬”,最高层级为“无违”。因此,父母要求子女的言行、生活细节,皆需遵循父母意愿,不得有半点自主空间。子女自幼接受此类教育,其人格必然受到扭曲,在家中面对父母,在外面对地主、官僚等强势者,皆会自然顺从、忍气吞声。国家正是凭借构建这样的伦理道德次序来稳固统治阶级的权势。他们在从家庭踏入社会的过程中,自然而然地形成了这种压抑个性。由于中国古代家庭教育强调服从、“有顺无违”,未给个人与个性留下任何空间,平等、自主的观念在古代几乎不存在,从而导致社会成员

^①Sol Rubin. *Crime and Juvenile Delinquency: A Rational Approach to Penal Problems*, New York, Oceana Publications, 36.

^②参见李海峰:《家庭教育的司法保障——基于〈家庭教育促进法〉第八条展开》,载《学术探索》2023 年第 7 期。

^③参见李泊毅:《家庭教育指导令的规范化》,载《预防青少年犯罪研究》2022 年第 3 期。

缺乏个性意识与权利意识,形成了人们近乎屈从的顺从心态。所以,过渡干涉家庭教育自主性,会导致未成年人缺乏独立思想与意识,惰性心理极为严重,结果是不仅侵犯了未成年人的权益,也对国家的长远发展造成不利影响。

若将家庭教育的判断权交由家庭成员之外的主体,这样必然会导致家庭所具有的温情和关爱逐渐消失,各项家庭教育的手段流于表象,立法仅有形式而意义尽失。家庭教育是公民私领域的主要范畴,家庭成员要根据自身的经验、知识、性格和家庭传统来对个人成长和发展进行判断,而非完全复制社会传统、惯用习俗和他人经验。当家庭功能失灵时,国家才有介入的必要。同时,国家介入有帮助未成年人的积极作用,过度介入有侵害家庭教育私领域的风险。基于现代社会国家治理经验,任何国家权力都具有天然的扩张性和易腐性。^①因此,国家在家庭教育中应是对家庭提供物质和资源的辅助性角色。

2.家庭教育指导令在家庭教育指导手段中应当处于辅助地位。国家对家庭教育的介入不仅有家庭教育指导令,还有家庭教育指导。家庭教育指导是指国家和社会为家庭教育提供指导、支持和服务。近年来,政府出台多部政策,将家庭教育指导服务作为基本公共服务,构建家庭教育指导服务体系。^②相比于家庭教育指导的服务性,家庭教育指导令具有惩罚性和强制性,家庭成员之间的关切和情感是强制性手段无法完全涵盖和调整的,因为法律无法准确调节家长对于未成年子女的爱。解决家庭中的诸多问题最合适指导、调解等柔性手段,遵循个别的要求,采取具有选择性的灵活解决方案,以促使当事人自愿改变不利于家庭关系和谐的决定,自动改善家庭教育活动。家庭教育指导能够稀释国家介入家庭教育的强制性,缓和国家对家长教育权的限制性。因此,如果通过家庭教育指导就能解决的家庭问题,就不应当适用家庭教育指导令。家庭教育指导令处于辅助性位置,能防止国家过度介入家庭教育。

(三)利益衡量应当遵循最有利于未成年人原则

家庭教育指导令的有效实施,能够有效降低家庭矛盾与冲突的发生频率,促进亲子关系的和谐发展,为未成年人营造一个充满温馨、和谐与健康的成长氛围。但家庭教育涉及多方利益,国家的介入像一把双刃剑,在保护未成年人利益的同时,可能会侵害家长的教育自主性。因此,要明确价值衡量当中的价值判断标准,找到各方利益的黄金分割点。

1.家庭教育多元主体的利益衡量。利益衡量的前提条件是厘清家庭教育指导令中牵涉到的各类主体利益。在家庭教育指导令中,直接的利益相关方一是国家,二是家长,三是未成年人。因此应从国家、家长、未成年人三个维度考虑,综合评价国家介入家庭教育的正负效果,促进家庭教育指导令效能的实现。

(1)国家利益角度。家庭教育原本属于私人领域的事务,其重要性逐渐被社会广泛认识,如果家庭教育方式不当,可能会对个人的成长产生负面影响,进而对整个社会稳定造成潜在威胁。因此,国家开始介入家庭教育,以确保其符合社会规范和国家利益,从而维护社会秩序和促进国家长远发展。^③历史上,国家介入家庭教育可追溯至古罗马,当时法律开始限制家长权力以满足国家对劳动力和军事力量的需求。^④现代社会中,国家通过教育政策和行政管理来实现其教育目标。^⑤然而,国家权力的扩张可能导致对家庭教育自主权的过度干预,因此需要对国家教育权进行限制以保护家长和未成年人的利益。

(2)家长利益角度。家庭教育由家庭成员通过指导和示范对未成年人施加影响。它根植于家庭,具有正当性和合理性,符合道德和法律标准。在现代教育出现之前,家庭教育是唯一形式,父母拥有教育子女的绝对权力。家庭教育历史悠久,起源于家庭和种族维系的需求。在古罗马,家父对子女有绝对权威,在中国古代,家长对未成年子女也有控制权。因为家庭是社会生产的基本单位,对子女的控制意

①参见邓静秋:《家庭教育促进法的宪法逻辑》,载《苏州大学学报(教育科学版)》2021年第4期。

②政府部门相继颁布《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》《关于指导推进家庭教育的五年规划(2021—2025年)》等政策文件,明确提出逐步将家庭教育纳入政府教育职能,将家庭教育指导服务纳入基本公共服务,构建覆盖城乡、公平优质、均衡发展的家庭教育指导服务体系,形成有群体适应性的家庭教育指导服务模式。

③参见罗爽:《我国家庭教育立法的基本框架及其配套制度设计》,载《首都师范大学学报(社会科学版)》2018年第1期。

④参见姚建龙、公长伟:《未成年人保护中的国家亲权理念——以新未成年人保护法为重点》,载《预防青少年犯罪研究》2021年第1期。

⑤参见褚宏启:《中国教育管理评论(第3卷)》,教育科学出版社2005年版,第411页。

味着控制了劳动力。随着社会发展,现代教育引入西方儿童本位思想,加之家庭结构变化,家长教育子女更多是出于教育理想和建立良好亲子关系。家长根据自己的理念培养子女,与孩子沟通和参与活动,建立亲密关系。对比之下,封建社会时期,家庭教育与国家意志一致,现代教育体系更关注个体发展,家长教育目标多样化。因此,现代社会家长与国家教育目标时常发生冲突,国家过度介入可能影响家庭教育自主性。

(3)未成年人利益角度。家庭教育作为一种基于亲权的教育方式,受教育的主体为未成年人。从不同视角审视,未成年人利益具有多样性表现。国家中心模式主张国家应以培养国家的建设者和加班人为目标;父母中心模式强调父母对子女需求的深刻理解,并促进儿童发展的多样性;未成年人中心模式则重视激发其潜能和自主性。不同主体角度的未成年人利益内涵也并不相同,在分析未成年人利益时,应以未成年人的个人意愿为出发点。他们在家庭教育中期望获得情感支持、安全感、有效沟通、自主尊重、引导启发、鼓励肯定以及稳定的家庭环境与支持。简而言之,未成年人的利益体现在家庭教育对其多样化需求的满足。然而,在家庭教育中,未成年人的自主意识尚未成熟,需求和想法多变,经常与家长和国家的长期教育目标相悖。当未成年人的利益与家长或国家的教育目标发生冲突时,他们往往处于弱势地位,容易被控制和强迫,导致利益难以得到保护。因此,在家庭教育中,应更加关注未成年人的利益,确保他们的权益得到充分保障。^①

2.最有利于未成年人原则应当是家庭教育指导令的价值判断。在家庭教育中,国家、家长和未成年人的利益在家庭教育中并不总是一致,即使在三者都以保护未成年人为本位的前提下,对何为对未成年人有益也持有不同观点。当未成年人利益与父母利益甚至国家利益发生冲突时到底如何解决,仍然是一个巨大的难题。

从古至今,家长对子女的态度经历了视为获得工具——缺乏关注——儿童本位的变化过程,当今社会也终于意识到了未成年人的重要性和未成年人的弱势地位。法国著名的社会史专家菲利浦·阿利埃斯曾在书中写道:“对于生活儿童还不够成熟。在让他们进入成人世界之前,儿童必须受到一种特殊的对待,一种保护性的隔离。”^②在家庭教育指导令的利益衡量中,应考虑能力发展理论,认识到未成年人的脆弱性。根据这一理论,利益衡量应以实质平等为原则,天平应向未成年人作适当倾斜,确保未成年人的利益得到优先考虑。因此,最有利于未成年人的原则是合理且正当的,有助于实现家庭教育指导令的公平适用。

最有利于未成年人原则是儿童利益最大化原则的中国化表现,《儿童权利宣言》提出了儿童利益最大化原则。家庭教育指导令在把握最有利于未成年人原则时,关键是要看对未成年人“最有利”的是什么。^③因此,在运用这一原则时,应把握一下两个面向:首先,需考虑地域差异。不同地区未成年人的经济和文化背景各异,家庭教育指导应兼顾文化差异带来的教育理念多样性,保持灵活性。同时,不同国家家庭教育历史不同,对“最有利”原则的理解也应有所区分。例如,美国许多州将父母打孩子视为重罪,而我国虽禁止家庭暴力,但在“棍棒底下出孝子”等传统观念影响下对此类行为的管理并不严格。因此,最有利于未成年人的原则存在不确定性,司法机关在制发家庭教育指导令时,应考虑这些差异性来行使裁量权。其次,必须确立原则性内容。尽管无法制定统一标准以适应差异性,但若无原则性内容,最有利于未成年人原则将失去意义。例如,《儿童权利宣言》(1959)强调结果式立法,将最大利益定义为儿童在健康、正常状态及自由与尊严条件下,全面发展的机会与便利。最有利于未成年人原则应借鉴国际经验,确保有序运用,处理未成年人利益与家长、国家利益的冲突。^④

四、家庭教育指导令的优化路径

遵循比例原则对当前家庭教育指导令的分析,以及对家庭教育指导令的理论建构,对应上文家庭教

①参见林建军:《家庭教育法的调整对象及其逻辑起点》,载《河北法学》2021年第5期。

②徐国栋:《论民事屈从关系——以菲尔麦命题为中心》,载《中国法学》2011年第5期。

③参见王广聪:《论最有利于未成年人原则的司法适用》,载《政治与法律》2022年第3期。

④参见邓丽:《最有利于未成年人原则的实践基础与制度理性》,载《政治与法律》2024年第6期。

育指导令的三重困境提出以下完善建议:

(一) 设定“温和”法律责任

基于适当性原则,家庭教育指导令的手段必须契合其目的,家庭教育指导令的目的是保护未成年人、促进家庭和谐与社会稳固发展。通过上文的探讨,家庭教育指导令是以教育性为主,惩罚性为辅。弱惩罚性意味着对拒不接受家庭教育指导令的惩罚手段要相对温和。

1.以扣除保证金作为财产性法律后果。在家庭教育立法草案一审稿中,对于拒绝执行家庭教育指导令的家长,原拟定了包括罚款、拘留等在内的惩罚性措施。然而,鉴于审议过程中专家提出这些措施过于严苛,可能引发国家过度干预家庭教育的担忧,上述惩罚性条款最终被悉数移除。罚款机制旨在通过对失职家长施加财产损失,使其承受经济上的痛苦,以此作为惩罚手段。然而,此类财产损失具有不可逆性,导致了财产的永久性转移。并且,经济条件较差的家庭更易出现失职行为,而永久性的财产转移不仅可能加剧家长的愤怒和抵触情绪,还可能使这些家庭面临更为严峻的经济困境,从而削弱家庭教育指导令的实际效力。鉴于家庭教育指导令的惩罚性质应为辅助性,因此,设置此类惩罚措施在科学性和合理性上均存在疑问。

保证金制度作为一种确保义务履行的机制,其表现为一种临时性的财产转移至指定账户。与罚款不同,若监护人积极履行其监护职责,该保证金将全额退还,从而避免了实际的经济损失。此外,保证金的预先缴纳能够有效激发监护人履行义务的主动性。相较于单纯的训诫措施,保证金制度通过引入适度的强制性,为家庭教育指导令的执行提供了更为有力的保障,从而确保了家庭教育指导令的实施效果。

2.以成为撤销监护权参考因素作为非财产性法律后果。家庭教育指导令的制发是为了纠正失职家长的行为,协助其提升家庭教育能力。如果失职家长宁愿被扣除保证金也不履行义务,也就意味着家庭教育指导令并未发挥效能,失职家长仍然实施着不正确的家庭教育,这可能说明该部分家长已经不适合再作为未成年子女的监护人。因此,有检察院提出将丧失监护权作为不接受家庭教育指导令的可能性后果之一。剥夺监护权是对未成年人权益的保护,但也是一项较为严厉的惩罚,不应是教育性为主的家庭教育指导令应当设置的法律后果。如果将家长履行家庭教育指导令的情况仅作为法院决定是否撤销监护权的参考因素,将发挥更好的制度效果。此种考量,既对失职家长产生了一定的震慑效果,又弱化了撤销监护的惩罚性。^①

(二) 构建事前审查体系

必要性原则是指行政主体实施行政行为不能超越实现行政目的的必要程度。因司法实践对“不正确实施家庭教育”、家长教育行为与未成年人利益受损之间因果关系等问题的理解偏差,导致许多本不必适用家庭教育指导令的案件被制发家庭教育指导令。因此,应当对制发家庭教育指导令有更严谨的程序和明确的标准。

1.构建事前审查程序。在《家庭教育促进法》四十九条中规定了“可以根据情况”对父母或监护人制发家庭教育指导令。司法实践中出现的适用偏差,就是没有严格审查案件是否有适用家庭教育指导令的必要。因此,需要对是否适用家庭教育指导令进行形式审查和实质审查。形式审查方面,需要审查是否符合立案条件。在实质审查方面,首先要对是否符合家庭教育指导令签发标准进行审查,其次要对当事家庭进行家事调查评估,了解未成年子女的生活、学习现状、心理健康、与父母的关系、家庭财产状况等。依据调查情况,司法机关决定是否签发家庭教育指导令,以及制定家庭教育指导令的针对性内容。

2.明确和细化审查标准。家庭教育指导令在司法实践中的适用不当,基本出现在《家庭教育促进法》第四十九条的第二种情形,即“未成年人的父母或者其他监护人不正确实施家庭教育,侵害未成年人合法权益的”。其中,该条目涉及到三个要件标准模糊:家长的行为是否属于“不正确实施家庭教育”、未成年人利益受到侵害是否包含可能受到侵害、“不正确实施家庭教育”与“侵害未成年人合法利

^①参见王广聪、王进:《家庭教育促进法中强制干预的督促监护问题研究》,载《法学杂志》2023年第6期。

益”之间是否有因果关系。

首先,是否存在失职行为的标准。如果是《家庭教育促进法》第四十九条规定的第一种情形,成年人存在严重不良行为或者实施犯罪行为,就可以直接认定有必要适用家庭教育指导令。如果是《家庭教育促进法》第四十九条的第二种情形,需要审查以下几点:第一点,审查家长的行为是否属于“不正确实施家庭教育”。在审查的过程中要重点区分不正确实施家庭教育 and 不正确履行监护职责。第二点,未成年人利益是否受到侵害的标准。这个问题的关键在于,是否将有可能发生利益侵害的情形加入其中。有学者认为,在可能发生侵害时就适用家庭教育指导令能够更有效的保护未成年人利益。^①实际上,家庭教育指导令不适用于可能侵害未成年人利益的情形。家庭教育指导令具有一定的强制性、惩罚性,对并未实际损害未成年人的家长进行惩罚,缺乏理论正当性,同时,会让本不充足的家庭教育指导资源更加紧张。第三点,“不正确实施家庭教育”与“侵害未成年人合法权益”之间是否有因果关系的标准。如上文提到的未成年人被性侵的案件中,家长也被追究了疏于关心的责任,收到家庭教育指导令,但二者之间并没有直接的因果关系。针对此类问题,可以采取负面赋分机制。当监护人行为存在不利于未成年人健康成长的因素时,会给予相应的扣分。例如,监护人忽视孩子的教育、情感需求,或者存在家庭暴力、虐待等行为,都可能导致较高的负面赋分。设定 60 分为判断关联性的一个阈值。如果总分超过 60 分,则认为未成年人问题行为与监护人行为之间具有显著的关联性。

(三) 提供专门化家庭教育支持

均衡性原则要求国家对家长教育权的侵害不得超过所追求的行政目的价值。当国家教育权、家庭教育权和未成年人受教育权产生利益冲突时,应当坚持最有利于未成年人原则协调各方利益。

1. 概括性规定家庭教育的内容和方式。《家庭教育促进法》中的第十六条和第十七条较为详细地罗列了家庭教育指导的内容和方式。尽管条款采用了指导性规则的形式,但在实践中仍被作为“不正确家庭教育”的判断依据,受社会、文化、经济等多重因素的影响,这些统一且详细的规则过度限制了家长的教育权。因此,应当对家庭教育指导令的方式和内容进行更为概括性的规定。

立法对于家庭教育的内容和方式应当采用总体性、原则性、共同性意义的描述,鼓励家庭根据孩子的兴趣和特长进行个性化教育,而不是具体详尽的规定。同时也可以列举一些建议性的家庭教育内容和方式,列举的内容应当是结合实际,绝大多数家长能够实现的。倡导家庭注重孩子的全面发展,包括德、智、体、美等方面,但不具体规定每个方面应达到的标准。在适用家庭教育指导令的审查过程中,应当由多名专业人员结合当事人的实际情况、各种影响因素进行专门性的判断。^②

2. 制定针对性的指导方案。基于家庭机构和经济水平的差异,并非所有家长都能达到正确家庭教育的全方位标准。对于工作繁忙的家长来说,很难对其课以投入大量时间陪伴子女的义务;对于文化水平不高的家长来说,很难对其课以掌握较高教育能力和专业知识的义务;对于经济困难的家长来说,很难对其课以培养子女广泛兴趣爱好的义务。^③因此,家庭教育指导令的内容应当有所区分。

家庭教育指导令在制发前,应与家长进行充分沟通,听取其意见和诉求,确保指导令的内容符合家长的实际情况和需求;家庭教育指导令在制发后,对于应明确家长对家庭教育指导令不服的救济途径,救济应当设定较短的复议期限,可以规定家长在收到家庭教育指导令五日内有权提出复议申请。复议程序尽可能简化,可以规定复议机关在审查复议申请时,主要依据当事人提供的书面材料和证据进行审查,无需进行过多的口头听证或调查取证;在执行过程中,应建立定期反馈机制,及时了解家长的执行情况和遇到的困难,为其提供必要的帮助和支持。

①参见谭佐财:《“依法带娃”:家庭教育指导令的法律实现》,载《兰州学刊》2022 年第 10 期。

②参见杨雯清:《〈家庭教育促进法〉的实践困境与优化路径——基于基本权利功能理论的分析》,载《中国青年社会科学》2022 年第 6 期。

③参见余雅风、姚真:《论家庭教育立法的宗旨及规范重点——基于国外立法的思考》,载《华南师范大学学报(社会科学版)》2021 年第 3 期。

结语

为了让未成年人能接受良好的家庭教育,家庭教育指导令既要正向地为家长提供指导、教育,又要反向地打击、惩罚“问题家长”。司法机关在适用时要保障家庭教育指导令的有效性,同时还需警惕过度介入家事而侵犯私人利益,这在实践中往往就会出现家庭教育指导令的不当签发。家庭教育指导令作为一个新生手段,从价值判断、功能定位等法律性质界定,到启动方式、执行保障等程序性保障都需要进一步厘清。比例原则是公权力行使职权时的尺,敦促公权力选择对公民权利侵害最小的方式,并确保所采取的措施与所追求的目的之间具有合理的比例关系。家庭教育指导令涉及多重利益的特性,与比例原则平衡利益冲突的功能不谋而合,比例原则可以作为家庭教育指导令的行动指南,协调国家、家长和未成年人之间的利益冲突。从适当性原则、必要性原则、均衡性原则的视角出发,对家庭教育指导令进行规则完善,实现家庭教育指导令促进未成年人健康成长、家长不断自我提升、国家稳定发展的最终目标。

Subject:System Improvement of Family Education Guidance Order from The Perspective of Proportionality Principle

Author & unit:LI Xue(Law School,Hainan Normal University,Haikou Hainan 570100,China)

Abstract:The implementation of the "Family Education Promotion Law" has drawn significant attention to the family education guidance order. While it is widely applied, it has also given rise to numerous disputes. The predicaments of the family education guidance order mainly manifest in three dimensions: rules, practices, and values. The principle of proportionality, as an effective tool for balancing conflicting interests, holds significant inspiration for addressing the current predicaments. Based on the guiding analysis of the three sub-principles of the principle of proportionality, namely the principle of appropriateness, the principle of necessity, and the principle of equilibrium, the family education guidance order should adhere to the rule of emphasizing education while supplementing with punishment in rule formulation; it should clearly define its auxiliary positioning in practical application; and in the process of value measurement, the value judgment should be based on what is most beneficial to minors. In accordance with the above-mentioned expected definitions of the family education guidance order, its institutional improvement should be carried out from three aspects: setting "mild" legal responsibilities, constructing a prior review system, and providing specialized family education support.

Key words:family education guidance order; proportionality principle; state educational power; the principle of best interests of minors; right to education

[责任编辑:王德福]